

1520554-42.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... mais, porque, nestes autos o réu responde pelo crime de tráfico, na modalidade de "guardar e ter em depósito" o que veio comprovado nos autos.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1520554-42.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520554-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO SILVA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

BRUNO SILVA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, segundo apurado, no dia 25 de agosto de 2021, em período de calamidade pública, por volta das 09h50min, na Rua Mouquim, nº 65, Capão Redondo, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito 1408,8 gramas de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como MACONHA, acondicionada em 580 invólucros plásticos e 1083,4 gramas de COCAÍNA, acondicionada em 1680 invólucros plásticos, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado, apresentando resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução durante a instrução foram ouvidos dois policiais, duas testemunhas de Defesa e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou, em suma, pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pleiteou, pela absolvição do réu por insuficiência probatória e em caso de eventual condenação buscou, em suma, a fixação da pena base no mínimo legal e o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante as alegações da Defesa, analisando as provas colhidas nos autos, há

provas suficientes para a condenação do acusado.

Assim vejamos: Os dois policiais ouvidos em juízo afirmaram que havia uma investigação na delegacia de polícia que partiu da morte de um policial, sobre a ocorrência de tráfico ilícito na região e por meio de informação obtida no trabalho de campo, tomaram conhecimento de que o réu, vulgo macaquinho era o responsável pela guarda e distribuição de drogas na região.

De posse dessas informações se dirigiram ao local mencionado na denúncia e após breve campanha visualizaram o réu saindo de casa e de pronto o abordaram, ocasião em que o réu ao ser indagado sobre as drogas confirmou que realmente guardava drogas na sua residência, levando os policiais até seu quarto, onde as drogas foram encontradas dentro de uma mochila, que estava próxima a um guarda-roupa. Segundo o réu, ele havia acabado de sair da prisão e que em razão de problemas no interior do presídio, acabou contraindo uma dívida e foi obrigado a guardar as drogas para não sofrer represálias. Diante disso o réu foi apreendido e levado à Delegacia de Polícia, antes contudo, pararam em um descampado, onde segundo o informante também havia drogas, mas como nada foi encontrado se dirigiram ao distrito para a lavratura da prisão do réu.

As duas testemunhas de defesa, ouvidas em juízo, não presenciaram o momento em que as drogas foram encontradas no quarto do réu.

Márcia, que trabalhava com a mãe do acusado, em uma oficina na parte debaixo da residência, disse que estava chegando para trabalhar após receber as chaves do local foi abordada pelos policiais que determinaram que ele lhe entregasse as chaves da residência, e perguntaram sobre uma pessoa de nome "boy". Como ela não conhecia esse "boy", foi levada à oficina-garagem junto com um dos policiais enquanto os outros subiram para o interior da residência e voltaram trazendo Bruno, que segundo eles seria levado apenas para averiguação. Disse que Gabriela chegou no local logo após e também permaneceu com os policiais. Afirmou, ainda, que Eliana também trabalha no local mas não tinha chegado ainda ao trabalho e não estava na oficina, quando os policiais chegaram.

A outra testemunha de Defesa, Eliana disse que é vizinha de Bruno e trabalha com sua mãe. No dia dos saiu para fumar na área de sua casa e viu dois policiais descendo de um carro e se dirigindo à casa de Bruno. Foi à padaria e ao olhar para trás viu os policiais abordando Márcia e quando retornou os policiais já estavam dentro da residência de Leda, mãe do Bruno. Em razão do ocorrido, não foi trabalhar e foi a casa de sua irmã, ocasião em que vi o carro da polícia parado com Bruno dentro do camburão. Disse que depois foi ao local e tomou conhecimento dos fatos por Márcia e que Leda nada lhe disse pois estava em "choque".

O réu, por sua vez, negou a prática do crime, disse que acordou com um chamado na porta de seu quarto, por um tal de "boy". Abriu a porta e os policiais entraram já afirmando que "a casa havia caído". Disse que não conhecia "boy" e eles entraram no quarto e revistaram toda a casa e nada encontraram. Sua mãe se aproximou e como estava muito nervosa foi levada pelos policiais para a parte de baixo da residência. Afirmou que ficou sentado no chão e foi levado à Delegacia apenas para "averiguação".

No caminho os policiais pararam o veículo na via, com ele dentro da viatura, ocasião em que viu Eliana, e após aproximadamente meia hora, alguns policiais voltaram da favela com uma sacola nas mãos e rumaram para a Delegacia. Disse que após algum tempo na Delegacia policiais se aproximaram e afirmaram que queriam R\$ 20.000, 00 para ser liberado e que se não arrumasse o dinheiro os policiais iriam afirmar que as drogas que eles encontraram na favela estavam com o réu. Disse que após conversar com sua mãe e seus familiares conseguiram juntar R\$ 10.000,00, mas que os policiais não aceitaram esse valor e ele acabou sendo preso.

Ressalta-se que em nenhum momento disse que os policiais invadiram sua residência. Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, ao contrário do alegado pela Defesa, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Por primeiro, porque a negativa do réu e ainda o fato por ele narrado de que após ter sido abordado pelos policiais que pediram R\$ 20.000,00 para libera-lo e que não aceitaram a metade do dinheiro que fora conseguido por sua mãe e sua família, não é crível e não vem amparada por quaisquer outros elementos de convicção.

Veja-se que neste ponto, poderia ter trazido ao juízo um de seus familiares para comprovar a oferta de metade do valor requerido pelos policiais e não o fez. Sua mãe não foi arrolada para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Por outro lado a citada pessoa de Gabriela segundo o depoimento de Marcia, também chegou ao local e que teria presenciado a chegada da polícia na residência de Bruno, também não foi arrolada para confirmar as alegações. Por outro lado, Eliana, não estava em frente a sua casa no momento em que Bruno desceu com os policiais já que foi à padaria e apenas viu os policiais chegando ao local e segundo ela, entrando após breve conversa com Márcia.

O réu por sua vez, disse que sua mãe estava na parte de cima da casa. Ou seja, cada testemunha de Defesa deu uma versão para a entrada dos policiais na residência e apesar disso nenhuma delas ou mesmo o réu afirmaram que houve "invasão do domicílio" do acusado.

Em contrapartida, os depoimentos dos policiais convergem em mesmo sentido e os dois foram uníssonos em afirmar, em ambas as oportunidades em que foram ouvidos afirmaram que após investigação e trabalho de campo, foram informados de que o réu era o responsável pela guarda e distribuição das drogas e que se dirigiram ao local mencionado e encontraram Bruno que após ser indagado sobre as drogas, confessou os fatos, levando-os até seu quarto, onde as drogas foram encontradas.

Neste ponto, apenas a título de argumentação e ainda em razão do requerimento da Defesa, reiterado a fls. 210 e da juntada das informações de fls. 211, ressalta-se que em nenhum momento os policiais ouvidos afirmaram que havia na Delegacia de Polícia um inquérito em que o réu constava como investigado. O que eles disseram foi que após a morte de um policial civil na região, há alguns anos, passaram a investigar o local e conseguiram amealhar várias informações de pessoas da região, no sentido de que lá havia tráfico ilícito de entorpecentes que durante este trabalho de campo receberam a denúncia de que na casa do acusado, eram armazenadas as drogas para distribuição e por isso para lá se dirigiram, ocasião em que acabaram sendo levados pelo próprio réu ao local onde as drogas estavam.

É de asseverar, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, muito embora tenha a il. defesa tentado caracterizar de tal forma.

Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais. Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu de uma denúncia anônima, sem que haja qualquer indício que qualquer perseguição pelos policiais houvesse em relação ao acusado. Nesse sentido: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia, merece total acolhimento a pretensão punitiva.

Ressalta-se, ainda, que a quantidade de droga apreendidas, sua forma de acondicionamento, bem como o dinheiro encontrado com o réu, confirmaram a denúncia anônima e são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei

11.343/06, ainda mais, porque, nestes autos o réu responde pelo crime de tráfico, na modalidade de "guardar e ter em depósito" o que veio comprovado nos autos. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Por outro lado, a materialidade do delito veio devidamente comprovada pela juntada do auto de apreensão e exibição da droga, que estava dentro de uma mochila, (fls. 07), bem como pelo laudo pericial de fls.159/161, com resultado positivo para maconha e cocaína.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, já tendo sido condenado definitivamente pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes, autos 0001200-74.2018.8.26.0628 e havia sido progredido para o cumprimento de pena em regime aberto, há mesmo de um mês de sua prisão em flagrante. (fls. 41), o que será levado em consideração na segunda fase da aplicação da pena. Além da condenação referida, também foi condenado definitivamente pelo crime de roubo autos nº 0005724-89.2009.8.26.0609, (fls.42/43), fato este que configura maus antecedentes e nos permite aumentar a pena base em 1/6, nos termos do disposto no art. 59 do CP, notadamente por sua personalidade voltada para o crime, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Neste ponto, não há que se falar em desconsideração da condenação acima apontada apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase, há que se reconhecer a agravante da reincidência atestada nos autos, e também que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Ademais, respeitadas posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido já se posicionaram nossos Tribunais: "Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - APR:

15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda:“(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão.Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021). Assim a pena deve ser exasperada em mais 1/5 chegando-se ao patamar de 7 anos de reclusão e 699 dias-multa. Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de tráfico, diante de reincidência e dos maus antecedentes já que demonstrado está que o réu se dedica a atividades criminosas, já que ao ser solto, após cumprir parte de sua pena pelo mesmo delito novamente voltou a delinquir e foi preso.

Nesse particular, não há falar em bis in idem pelo simples fato de a reincidência servir como fundamento para agravar a pena e também impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, não se vislumbrando, por aqui, qualquer inconstitucionalidade.

Isto porque, “...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado.

Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, “não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente” (HC 118403/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009).” (TJSP, Apel. Crim. nº 990.10.184009-0, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro).

Além disso, “O agravamento da pena pela reincidência também está correto e decorre de expressa determinação legal. Não ocorreu bis in idem. Não é raro que uma mesma circunstância reflita em mais de uma direção. O reincidente, v.g., não tem direito a sursis, por

expressa disposição legal. Não obstante, o magistrado é obrigado a exacerbar sua pena, porque a reincidência também é agravante. Seguindo o mesmo raciocínio, no caso ora em exame, não aplicável a causa de redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei nº 11.343/06, dada a recidiva, a qual também é usada para agravar a pena, por determinação legal.” (Rev.Crim. nº 990.09.160794-0, 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eduardo Pereira).

O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta dessa conclusão: “Não há que se falar em bis in idem na utilização da reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação da minorante contida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, visto que, consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, é possível que um mesmo instituto jurídico incida em momentos distintos da dosimetria da pena, desde que haja comando legal específico nesse sentido. Precedentes.” (HC 202.163/SP, Rel.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para CONDENÁ-LO à pena de 07 anos de reclusão e ao pagamento de 699 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, já que não há nos autos provas da condição econômica do acusado, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como sua reincidência, o réu cumprirá a pena em regime inicial fechado.

Em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP), Destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública, já que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos.

Diante disso, em cumprimento ao art. 316, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a decisão que determinou sua prisão preventiva.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD e oficie-se para destruição total dos entorpecentes.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06.

No que toca aos celulares e ao relógio apreendidos, decorridos o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, sem reclamação, desde já determino a aplicação do disposto no art. 123, do CPP. Oficie-se para leilão ou destruição se o caso.

Custas na forma da lei. Deixo de isentar o réu do pagamento da referida taxa, já que não compete a este juízo esta decisão, ainda mais porque, não há os autos qualquer prova da condição econômica do réu. (Apelação Criminal nº 1504000-37.2018.8.26.0228, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA